

1500602-26.2022.8.26.0266

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL VIEIRA PATARA

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Repte(a)(s):

Justiça Pública

Repto(a)(s):

PAULO SERGIO RODRIGUES JUNIOR

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

PAULO SERGIO RODRIGUES JUNIOR, vulgo "P.G", foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque no dia 05.04.2022, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

3ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, ., Centro - CEP 11740-000, Fone: (13) 3422-1215,

Itanhaém-SP - E-mail: itanhaem3@tjsp.jus.br

Processo nº:

1500602-26.2022.8.26.0266

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Repte(a)(s):

Justiça Pública

Repto(a)(s):

PAULO SERGIO RODRIGUES JUNIOR

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

PAULO SERGIO RODRIGUES JUNIOR, vulgo "P.G", foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque no dia 05.04.2022, por volta das 11h30min, Rua Monsenhor Vicente Zioni, n.º 820, Jardim Suarão nesta cidade e comarca de Itanhaém, o agente supra apontado guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 5,5 kg da droga Cannabis sativa L, popularmente conhecida por maconha e mais de 1,2 kg de cocaína, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 03.06.2022 (págs. 81/82).

O réu foi citado (pág. 186) e apresentou resposta escrita à acusação (págs. 195/197).

Durante a instrução, foi inquirida uma testemunha de acusação e o réu foi interrogado ao final (págs. 234/235).

O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado às págs. 35/39.

Em fase de memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, condenando-o nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu o acolhimento da preliminar de mérito para desentranhar as provas da materialidade delitiva ou, subsidiariamente que a pena seja mantida no mínimo legal, compensada a reincidência com a confissão, permanecendo inalterada na terceira fase, impondo o regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto.

É o relatório.
Fundamento e decido.

No que tange à preliminar de mérito formulada pela Defesa, visando desentranhar as provas da materialidade delitiva, razão não lhe assiste, pois o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade de "guarda" é do tipo permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, disso decorrendo ser permitida a realização da prisão em flagrante no interior da residência onde estão os entorpecentes, independentemente de mandado judicial.

A esse respeito, os seguintes precedentes:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO QUANDO CONFIGURADA A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, NATUREZA DELETÉRIA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA. SÚMULA N. 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade 'guardar' é do tipo permanente, cuja consumação se protraí no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial. No caso, os policiais militares perceberam o paciente em movimentação típica de tráfico e resolveram abordá-lo, ocasião em que o acusado entrou em luta corporal com um dos milicianos a fim de desarmá-lo e se evadiu do local, deixando cair um estojo contendo diversos entorpecentes. Ato contínuo, diante da informação de que o paciente teria se ocultado em determinada residência, se dirigiram ao local e lá adentraram, realizando a prisão em flagrante do ora paciente, bem como apreensão de diversas drogas. Nesse contexto, é Documento: 85275623 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 01/08/2018 Página 3 de 5 Superior Tribunal de Justiça certa a situação de flagrante, não havendo falar nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão. [...] Habeas corpus não conhecido" (HC 431.828/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 09/05/2018 - grifei).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes,

DJe 8/10/2010). [...] 3. Quanto ao ingresso forçado dos policiais na residência do paciente, destaca-se a realização de diligências prévias a indicar seu envolvimento com o tráfico de drogas. Os agentes avistaram pessoa consumindo entorpecente em frente a uma casa conhecida como ponto de venda de drogas e, a partir da abordagem desse indivíduo - com quem foi encontrada porção de substância semelhante a maconha -, ingressaram no domicílio do acusado, onde foram apreendidas porções de cocaína e crack, além de valores em pecúnia. [...] 5. Ordem denegada" (HC 434.688/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018 - grifei).

Posto isso, REJEITO a preliminar.

Ao mérito, pois.

A ação é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (págs. 05/10), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 16/18), pelo laudo de exame químico toxicológico (págs. 35/39), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução (págs. 141/142).

A autoria também é inconteste e deve ser atribuída ao acusado.

A testemunha arrolada pela acusação, Luciano Cesar da Silva, ouvido em Juízo, Policial Civil, disse que após pesquisa de campo fora possível identificar o acusado como um dos responsáveis pelo abastecimento do ponto de venda de drogas conhecido como "Boca dos Lírios". Na investigação observaram o réu e puderam visualizar onde ele estava guardando os entorpecentes. Com estas informações solicitaram a expedição do mandado de busca e apreensão, o qual fora deferido. No cumprimento do referido mandado, ao chegarem ao local, visualizaram o denunciado consumindo maconha no corredor da casa, contudo, ele conseguiu se evadir pelos fundos da residência, local em que foram localizadas as drogas apreendidas além de documentos do acusado e de sua companheira Pamela. Informou que não se recorda se a casa tinha identificação numérica, pois só havia um imóvel com identificação numérica no local, tendo em vista que é um local invadido.

Não há razão suficiente para invalidar o depoimento do Policial, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, pois, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que:

"(...) nada impede que policiais ou outros servidores públicos, como quaisquer pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos destes como se, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos de seus próprios servidores. A propósito do valor probante de testemunhos policiais, oportuno trazer à colação a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: 'VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e

jurisprudência." (HC 73518, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293)" (TJSP, Apelação nº 0009710-21.2011.8.26.0176, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, j. 31.03.2016).

O testemunho do Policial é suficiente para, com as demais provas carreadas aos autos, comprovar a ocorrência do fato típico, e embasar um decreto condenatório ao réu, vez que dotado de fé pública e idoneidade em sua alegação, mormente por ter corroborado o depoimento na fase inquisitorial.

O réu, Bruno Roberto Goes Da Silva, interrogado em Juízo, negou os fatos descrito na denúncia. Disse que não estava no local informado pelo policial, pois mora em outro bairro e, que inclusive, fora preso no bairro Guapurá. Afirmou que se envolveu com o tráfico, mas que não tem relação com a droga apreendida. Esclareceu, ainda, que pode ter sido visto andando de bicicleta pelo local, mas não soube especificar a data. Por fim, relatou que a localização de seus documentos no local da denúncia ocorreu em face do seu relacionamento com Paloma.

Pois bem.

Embora o acusado tenha negado a autoria delitiva, tais alegações não merecem prosperar em face da prova produzida nos autos e em Juízo. Portanto, a responsabilidade penal do réu é nítida, mormente pelas provas colhidas, em especial o auto de exibição e apreensão, somados aos depoimentos, tornando-se prova idônea da prática delitiva.

Necessário destacar, ainda, que o tráfico de drogas é praticado às ocultas, logo, para se prolatar decisão condenatória não há necessidade de uma sequência de provas plenas e fartas, pois tal situação não se coaduna com a realidade fática.

A decisão condenatória deve se basear em um quadro suficiente de elementos de convicção, que seja harmônico e convergente para configurar a conduta do réu, o que de fato ocorre no presente caso.

Ainda que assim não fosse, é sabido que todos os processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade, que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja, juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão.

Nem se diga que a existência apenas de indícios impossibilite um decreto condenatório, pois contrariaria doutrina e jurisprudência majoritárias:

"embora não leve à certeza, a jurisprudência tem admitido a condenação quando a prova indiciária for veemente ou então quando várias pequenas circunstâncias sejam, concordes até em detalhes. Um único indício pode levar à condenação, desde que veemente. Por indício veemente entende-se aquele que, dada a sua natureza, permite razoavelmente afastar todas as hipóteses favoráveis ao acusado. (...) Às vezes uma sucessão de pequenos indícios, coerentes e concatenados, igualmente podem dar a certeza exigida para a condenação. (...) Em tal hipótese não encontramos um indício que possa ser classificado como veemente, porém a sucessão e a coerência indicam a autoria com uma dose de razoabilidade bem marcante" (Da Prova no Processo Penal - José Q. T. de Camargo Aranha).

"A prova se faz não só de maneira direta, mas também por indícios e presunções, que devem ser analisados como todo e qualquer outro elemento de convicção, à luz do princípio do livre convencimento do Juiz. Os indícios, quando não contrariados por

contra indícios, ou por prova direta, autorizam o juízo e culpa do acusado e sua condenação." (TACRIM-SP - AC - Rel. Marrey Neto - JTACRIM 7/105).

Como se vê, ficou clara a prática de tráfico ilícito de entorpecentes por parte do réu, inexistindo nos autos qualquer fato que venha ilidir sua responsabilidade penal.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e diversidade, denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Devem-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. Al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Nesta toada, o conjunto probatório delineado nos autos é mais do que suficiente para empregar o decreto condenatório em desfavor do réu.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (págs. 91/94) observo que o réu possui maus antecedentes, desta forma, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a agravante de reincidência, majoro a pena em 1/2 (um meio), resultando uma pena provisória de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias, torno definitiva a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa.

Anote-se que a agravante da reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.".

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Segundo o mesmo jurista acima citado, inclusive na mesma obra, "na norma do §4º, para que se possa aplicar a diminuição de pena, afastou-se a possibilidade de ser reincidente ou ter maus antecedentes".

Desta forma, o réu sendo reincidente impossível à concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela.

Dito isso, presente a agravante da reincidência, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso II, do Código Penal), pela suspensão condicional da pena (artigo 77, incisos I e III do Código Penal), e a aplicação dos regimes aberto e semiaberto (artigo 33, §2º, alínea "a" do Código Penal).

Assim, também o regime inicial de cumprimento será o fechado.

Posto isto, CONDENO o réu BRUNO ROBERTO GOES DA SILVA qualificado nos autos, ao cumprimento de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, não podendo recorrer em liberdade, pois ainda presentes os requisitos da custódia cautelar.

Também, após o trânsito em julgado, oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens eventualmente apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Arbitro os honorários do defensor nomeado, se o caso, no valor máximo da tabela vigente, expeça-se o necessário.

P.I.C- Arquivando-se, oportunamente.

Itanhaém, 19 de dezembro de 2022.

RAFAEL VIEIRA PATARA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA